

1502848-29.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

MARCIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTOS

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502848-29.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502848-29.2020.8.26.0536 - Controle n.º 625/20

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

MARCIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 307, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 13h, na Rua General Câmara n.º 444, Centro, neste município e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de comercialização, treze porções de crack, droga capaz de causar dependência física.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, nas dependências do 1º Distrito Policial de Santos, MARCIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, dizendo que seu nome era Luis Henrique dos Santos Filho, e o fez com o fim de esconder seus antecedentes criminais.

Diz a denúncia que o acusado obteve as drogas para vender em circunstâncias não esclarecidas e, no dia dos fatos, policiais em patrulhamento pelo local que é conhecido pelo tráfico de drogas notaram atitude suspeita do réu e de indivíduo não identificado. O agente não identificado fugiu e o acusado tentou disfarçar.

Realizada a abordagem e busca pessoal, os policiais constataram que o réu trazia com ele treze pedras de crack, além de cinco chips de celular (Operadora Vivo) e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais).

Diz, ainda, a exordial que, tendo sido preso em flagrante delito, ao ser apresentado na Delegacia de Polícia, o acusado afirmou ser Luis Henrique dos Santos Filho, que na realidade é seu irmão.

Por fim, diz a denúncia que a droga se destinava à comercialização ilícita, devido à quantidade e à forma de embalagem da droga, ao fato de ser o local da prisão conhecido como ponto de tráfico, à atitude suspeita ostentada pelo acusado quando da aproximação policial e à apreensão de dinheiro e de cinco chips telefônicos (pp. 97/99).

Notificado o réu (p. 112), foi oferecida a defesa prévia de p. 121. Presente justa causa para o processamento da ação penal, a denúncia foi recebida (pp. 122/125), citando-se o acusado (p. 141).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Prejudicado o interrogatório em virtude da ausência do réu, declarado revel (pp. 199/200).

Em alegações finais orais, quanto à acusação pelo crime de tráfico de drogas, o Ministério Público requereu a desclassificação para reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, ante a dúvida razoável acerca da finalidade da droga apreendida. Quanto ao crime de falsa identidade, pleiteou a condenação, entendendo provados os fatos narrados na inicial, pontuando que a conduta objetivava ocultar seus antecedentes criminais. Na dosimetria da pena, pugnou pela consideração da agravante da reincidência. Por fim, sustentou a fixação de regime inicial diverso do aberto (gravação audiovisual – pp. 199/200).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, à vista do pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público, entendeu desnecessária a realização de exame de dependência toxicológica, requerendo a desistência do processamento desse pedido. No mérito, reiterou o pleito da Acusação pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, bem como pleiteou a absolvição por atipicidade do fato, sustentando que, por não ofender bens jurídicos alheios, tal conduta não poderia ser criminalizada. No que concerne ao crime de falsa identidade, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, entendendo tratar-se de crime impossível, uma vez que a Polícia detém os meios necessários para impedir que alguém se atribua falsa identidade. Por fim, sustentou que o crime de falsa identidade seria conduta acessória ao crime de tráfico pelo qual o réu estava sendo acusado e, diante da desclassificação, a condenação por esse delito produziria efeitos mais gravosos do que a conduta principal, o que feriria o princípio da proporcionalidade (gravação audiovisual – pp. 199/200).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de falsa identidade está comprovada pelo termo de interrogatório (p. 8), pelo boletim de ocorrência (pp. 12/14), e pelo documento de legitimação (p. 23), que confirmam que o acusado se identificou como se outra pessoa fosse.

A materialidade de crime previsto na Lei n.º 11.343/06 está satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (pp. 5/6), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (p. 7) e pelo laudo de exame toxicológico (pp. 114/116).

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

No que concerne ao crime de falsa identidade, o pedido inicial é procedente.

Entretanto, quanto ao crime de tráfico de drogas, não é possível declarar a procedência integral do pedido inicial, pois não há prova segura que indique que a droga apreendida fosse destinada ao consumo de terceiros.

Quando preso em flagrante delito, o acusado disse que mora em uma garagem perto do local dos fatos e que, quando abordado pelos policiais, portava dinheiro e pedras de crack para uso próprio. Não soube dizer onde adquiriu as pedras, nem o dinheiro, tampouco quem seria o indivíduo que se fugiu da abordagem policial ou onde essa pessoa poderia ser encontrada. Por fim, declarou ter conhecimento de que o local dos fatos é ponto de venda de drogas, afirmando que apenas passava por ali quando os policiais chegaram (p. 8).

Em juízo, preferiu a revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório (pp. 199/200).

Ubiranio Gama dos Santos, policial civil, informou que estavam realizando atividade de campo de polícia judiciária pelas proximidades do local e avistaram dois indivíduos. Devido à atitude de nervosismo demonstrada pelos suspeitos, resolveram abordá-los, sendo que um deles fugiu e outro lá permaneceu. Em revista pessoal, com o acusado encontraram treze pedras de crack, R\$ 40,00 em dinheiro e cinco chips de telefonia móvel, da operadora Vivo. O réu alegou que a droga seria destinada a seu consumo próprio. Declarou que o acusado aparentava estar sóbrio e com ele não havia nada que permitisse o consumo da droga. Por fim, disse não conhecer o acusado (gravação audiovisual – pp. 199/200).

Orlando Somaio Júnior, policial civil, narrou que estavam em diligências para cumprir uma ordem de serviço, porém, ao passar pelo local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico, avistaram dois indivíduos. Ao parar para fazer a abordagem, um deles fugiu para o interior de um imóvel, enquanto o réu tentou dissimular sua conduta, mexendo em uma bicicleta. Contou que, ao revistá-lo, encontraram treze pedras de crack, cinco chips da operadora Vivo e R\$ 40,00. O acusado disse que as drogas seriam para consumo pessoal. Diante disso, levaram-no à Delegacia de Polícia, tendo ele fornecido nome falso, tentando ludibriar os agentes de segurança. Como estava sem documentação, foi feita a identificação datiloscópica, constatando-se sua verdadeira identidade. Não encontrou com o réu qualquer objeto que permitisse consumir os entorpecentes. Não conhecia o acusado até então e não mais o viu (gravação audiovisual – pp. 199/200).

Vê-se, assim, que a prova é coerente e segura, dando ensejo à condenação pretendida quanto ao crime de falsa identidade.

Plenamente demonstrado que o réu identificou-se falsamente na ocasião da sua prisão em flagrante delito, fato este estampado no boletim de ocorrência e em seu interrogatório na fase inquisitorial, fornecendo os dados de identificação de seu irmão (pp. 8 e 12/14).

Não há como reconhecer que o meio empregado pelo agente tornasse impossível a caracterização de conduta criminoso, pois não haveria como serem ludibriados os policiais, uma vez que "a identificação criminal, consistente na coleta das impressões digitais (material dactiloscópico) não torna o meio absolutamente ineficaz" (TJSP; Apelação Criminal 2000114-29.2012.8.26.0439; Rel. Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2015).

Como aqui se demonstrou, o réu se identificou como Luis Henrique dos Santos Filho, que é seu irmão, e é certo que assim agiu para esconder antecedentes criminais. Também é certo que os policiais civis somente souberam seu verdadeiro nome e demais dados de qualificação pessoal após pesquisa realizada junto ao Instituto de Identificação, o IIRGD (p. 23).

Destaque-se, neste ponto, que os documentos aqui mencionados foram elaborados com base nas informações fornecidas pelo acusado, que não somente se identificou com o

nome de um familiar, como forneceu os dados de filiação e data de nascimento dele. E, por certo, não se cogita de conduta atípica, pois não há como entender que se trate de crime impossível pelo simples fato da polícia judiciária dispor de instrumentos que possam permitir a identificação de investigados.

Note-se, ademais, que efetivamente consumado o delito, tendo se exaurido por completo o iter criminis. Como leciona Capez, "consuma-se o crime com o ato de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade. Trata-se de crime formal, de maneira que o delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro" (Capez, Fernando. Curso de direito penal. v. 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 427).

Frise-se, por adequado, o entendimento sedimentado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Assim, comprovado está que o réu atribuiu-se falsa identidade, tratando-se de fato típico que configura o crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Do mesmo modo, não prospera a tese da Defesa quanto à ofensa ao princípio da proporcionalidade em virtude da condenação do réu pelo crime contra a Fé Pública. Impossível reconhecer que o crime de falsa identidade seja mera conduta acessória ao crime de tráfico de drogas, inicialmente investigado, revelando-se evidente que aqui se tem condutas que são fruto de desígnios autônomos.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, há suporte indicando o desate condenatório relativamente ao crime de falsa identidade.

Todavia, no tocante ao crime de tráfico de drogas, melhor sorte socorre o réu.

A prova reunida no contraditório não permite concluir que as porções de crack apreendidas em poder do acusado fossem realmente destinadas ao consumo de terceiros, ainda que não se possa dizer que se tratasse de pequena quantidade de entorpecente.

Os policiais civis confirmaram que abordaram o réu em conhecido ponto de tráfico de drogas, informando que o acusado não detinha nenhum objeto que permitisse o consumo dos entorpecentes, não aparentando que ele estivesse sob efeito de quaisquer substâncias.

Embora não se trate de apreensão de pequena quantidade de porções (13 pedras de crack), a quantidade de droga encontrada (2,2 gramas de crack, no total), por si só, não permite concluir que a droga fosse destinada ao consumo de terceiros.

Note-se que, em sede policial, o acusado informou que o entorpecente encontrado se destinava ao consumo próprio.

Na realidade, é bem possível que o réu estivesse realmente envolvido com a venda de drogas a terceiros. Todavia, não há comprovação de que ele tivesse a intenção de entregar os entorpecentes apreendidos a outrem e não há indicação segura da atividade ilegal descrita na petição inicial.

Nesta situação, é adequado que a dúvida favoreça o acusado, reconhecendo-se a desclassificação pretendida, pois nada nos autos indica, com segurança, que o entorpecente fosse destinado à outra finalidade que não seu consumo pessoal.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"ENTORPECENTES Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Impossibilidade. Apreensão de poucas porções de maconha na mochila do réu. Ausência de informações dando conta do comércio ilícito. Além disso, apelado que não foi visto em atos de traficância, tendo sido abordado apenas por nervosismo. Negativa do acusado em ambas as fases da persecução penal.

Circunstâncias da abordagem que não permitiram inferir o envolvimento dele no comércio ilícito. Impossibilidade de condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Apelo ministerial improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1510523-94.2020.8.26.0228; Rel. Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Apelante detido com 21 porções de crack, com peso de 2,02g. Insuficiência de provas. Inocorrência. Propriedade dos entorpecentes comprovada pela confissão do réu e pelos depoimentos prestados pelos

policiais militares. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Admissibilidade. Tese defensiva que não foi completamente infirmada pelo conjunto probatório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da extinção da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas, por seu integral cumprimento. Recurso defensivo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0001885-92.2016.8.26.0453; Rel. Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirajuí - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018).

Desta forma, parece que a desclassificação é desfecho adequado à situação aqui apurada, pois o réu admitiu o vício quando preso em flagrante e não há nos autos prova segura que indique que fosse entregar as porções de crack a consumo de terceiros.

Por fim, cabe asseverar a impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta, como pretendido pela Defesa, uma vez que típica e antijurídica a conduta delituosa prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, não ocorreu a descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal (artigo 28, da Lei n.º 11.343/06), mas tão somente mera despenalização decorrente da não previsão de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas.

Neste sentido:

"ENTORPECENTE - POSSE - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - DESCRIMINALIZAÇÃO - AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal - artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. RECURSO - VOLUNTARIEDADE. A protocolação de recurso submete-se à voluntariedade." (RHC 121584, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, processo eletrônico dje-266 divulg 05-11-2020 public 06-11-2020).

Isto posto, em sendo firme e seguro o contexto probatório, há suporte indicando o desate condenatório, reconhecendo-se a prática do delito de porte de droga, previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06.

Procede, em parte, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado por dois crimes de roubo majorado (autos n.º 0049415-13.2014.8.26.0114 - certidão de p. 194, e FA de p. 191; e, autos n.º 0017232-08.2011.8.26.0562 - certidão de p. 195, e FA de pp. 190/191), razão pela qual não faz jus à proposta de transação penal ou qualquer outro benefício despenalizador.

Em relação ao crime de falsa identidade, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Comprovada a reincidência, representada por duas condenações definitivas por roubo majorado, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 4 (quatro) meses de detenção, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

Deixo de aplicar a pena pecuniária por entender que, na situação aqui analisada, ela não é suficiente e nem adequada à reprovação da conduta criminosa comprovada. Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reconhecida reincidência representada por duas condenações definitivas por graves crimes contra o patrimônio, perpetrados mediante violência ou grave ameaça, iniciará o réu o cumprimento da pena de detenção em regime semiaberto.

No que concerne ao crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, em sede policial o réu afirmou que é usuário de entorpecentes e parece que, apesar de situações anteriores que o envolveram com drogas, não abandonou o consumo delas. Desta forma, é certo que não é caso de se impor ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga e isso porque não parece que a medida mencionada seja suficiente e necessária à reprovação da conduta aqui apurada.

Note-se que, como revelam certidões e antecedentes, há longa data o réu se vê envolvido com entorpecentes, razão pela qual essa medida parece inócua para a reinserção social e percepção dos maléficos efeitos do consumo de drogas.

Assim, e considerados esses critérios, tratando-se de reincidente, imponho ao

acusado a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 10 (dez) meses (artigo 28, inciso II, da Lei n.º 11.343/06), pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

A sanção penal é fixada nesse patamar em razão da reprovabilidade de seu proceder e visando adequada reinserção social, pois a medida visa o abandono do uso de drogas. Afora isso, é de se considerar que a legislação prima pela prescrição de "...medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção do usuário e dependente de drogas..." (artigo 1º, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Como se viu, é certo que os crimes de porte de droga e de falsa identidade foram praticados em concurso material.

Desta forma, e como dispõe o artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas impostas aos delitos descritos, somatória essa que alcança 4 (quatro) meses de detenção, e 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar MARCIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, pena essa a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, por incurso nas sanções previstas no artigo 307 do Código Penal e no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, ambos na forma do disposto no artigo 69 do Código Penal.

Sem pedido de decretação de prisão preventiva, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual n.º 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 30 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA